

임금 법제의 재건(再見)

권 오 성*

목 차

- I. 들어가며
- II. 임금의 개념
- III. 평균임금과 통상임금의 해석론
- IV. 임금의 보호
- V. 맺으며

I. 들어가며

근로계약은 본질상 근로자의 ‘시간’을 거래하는 계약이다. 근로자 측에서 보면 근로계약은 삶의 수요를 충족하는데 필요한 소득을 얻기 위해 생애 시간 일부의 처분권을 기업에 (설정적으로) 양도하는 거래이다. 이러한 이유에서 대다수 산업화된 국가들은 다소 양상을 달리하고는 있더라도 임금에 관한 다양한 방식의 보호를 노동법제의 핵심 내용으로 삼고 있다.

한편, 노동법의 영역에서 ‘임금’은 근로자가 근로계약에 따라 사용자에게 근로를 제공한 대가로 지급되는 금전을 의미한다. 이러한 의미에서 임금은 근로계약의 본질적인 요소이며, 근로자의 노무 제공 의무가 이행되면 일정 금액의 임금 청구권이 발생한다. 이때, 임금의 금액(金額)은

투고일 2024. 5. 20., 심사일 2024. 6. 4., 게재확정일 2024. 6. 9.

* 연세대학교 법학전문대학원 부교수

다른 근로 조건과 마찬가지로 최저임금법이나 근로기준법 등 법률의 제한 범위 내에서 단체협약, 취업규칙 또는 근로계약에 따라 결정되며, 예외적으로 확립된 노사 관행(慣行)으로 보충되기도 한다.

그런데, 매매나 임대차 등 여타 쌍무계약에 근거하여 지급되는 금전채권과 비교할 때, 임금채권은 다음의 두 가지 특징을 갖는다.

- ① 임금액 또는 임금액의 결정방법은 근로계약의 체결 또는 적어도 특정한 임금 지급(산정) 주기(週期)의 개시 이전에 정해진다.¹⁾
- ② 여타 쌍무계약에 따른 급부는 동시에 이행되는 것이 원칙이지만,²⁾ 임금은 일정한 임금 지급(산정) 주기를 전제로 그러한 주기에 상응하는 근로 제공 이후에 지급된다.³⁾

이처럼 임금의 액수 또는 임금액의 산정방법은 근로자가 근로를 제공하기 전에 ‘미리’ 결정되지만, 실제 임금의 지급은 해당 임금 지급(산정) 주기에 상응하는 노무가 제공된 이후에 이루어진다는 점에서 임금과 관련한 두 가지 오래된 문제가 발생한다. 먼저, 임금이 후급(後給)이라는 점은 ‘임금채불’의 근본적 원인이 된다. 다수의 근로자가 사업에 편입되

1) 근로기준법 제17조(근로조건의 명시) ① 사용자는 근로계약을 체결할 때에 근로자에게 다음 각 호의 사항을 명시하여야 한다. 근로계약 체결 후 다음 각 호의 사항을 변경하는 경우에도 또한 같다.

1. 임금

(…중략…)

② 사용자는 제1항 제1호와 관련한 임금의 구성항목·계산방법·지급방법 및 제2호부터 제4호까지의 사항이 명시된 서면을 근로자에게 교부하여야 한다. 다만, 본문에 따른 사항이 단체협약 또는 취업규칙의 변경 등 대통령령으로 정하는 사유로 인하여 변경되는 경우에는 근로자의 요구가 있으면 그 근로자에게 교부하여야 한다.

2) 민법 제536조 제1항은 “쌍무계약의 당사자 일방은 상대방이 그 채무이행을 제공할 때 까지 자기의 채무이행을 거절할 수 있다.”라고 하여 ‘동시이행의 항변권’을 규정하고 있다.

3) 민법 제656조 제2항은 “보수는 약정한 시기에 지급하여야 하며 시기의 약정이 없으면 관습에 의하고 관습이 없으면 약정한 노무를 종료한 후 지체 없이 지급하여야 한다.”라고 규정하고 있다.

어 분업(division of labor)의 방식으로 근로를 제공하는 근대적 생산방식 아래서는, 각 근로자가 제공한 노동의 결과는 자동적으로 기업에 귀속될 수밖에 없다.⁴⁾ 그러나, 그러한 노동에 대한 반대급부인 임금은 일정한 임금 지급주기가 지난 이후에 이루어진다. 따라서, 노무의 제공과 임금의 지급 사이의 기간에 발생할 수 있는 임금 지급에 관한 위험(예컨대, 기업의 도산 등)은 사실상 근로자가 부담할 수밖에 없게 된다.

다음으로, 기업(사용자)은 일정한 임금 지급(산정) 기간에 관한 임금액이 사전에 정해진 이후, 그 기간에 근로자에게 업무상 ‘지시’를 할 수 있다는 점에서 ‘착취(exploitation)’의 문제가 발생한다. 즉, 기업은 근로자로부터 사전에 정해진 가격(임금)으로 구매한 노동(력)을 보다 효율적으로 사용하여 더 많은 산출물을 획득하기 위한 다양한 노력을 하게 된다. 기업의 이러한 노력은 입장에 따라 ‘경영의 효율성’이라는 말로 표현되기도 하고, ‘착취’라는 말로 표현되기도 한다. 여하튼, 사전에 정해진 가격(임금)으로 노동력을 구매한 기업 측에서는 확보한 자원(노동)을 효율적으로 사용하기 위한 다양한 노력을 할 수밖에 없을 것이다. 반면, 근로자 측에서는 자신이 받기로 한 임금에 비해 ‘고된 노동’을 강요받는다고 생각할 수 있으며, 나아가 자신이 동종 산업에 종사하는 다른 근로자보다 더 착취당한다고 느낄 수도 있을 것이다.

필자는 임금 관련 법제를 ① 임금액은 사전에 결정되고, ② 기업은 정해진 가격(임금)으로 구매한 노동을 보다 효율적으로 사용하려고 노력할 수밖에 없다고 하는 임금을 둘러싼 주어진 두 가지 조건 아래서, 기업의 효율성 추구 동기를 어느 정도 긍정하면서도, 노동의 ‘착취’를 적정한 수준에서 제어하기 위한 법 기술이라는 관점에서 바라볼 필요가 있다고 생각한다. 기업의 사적 권력(private power)은 적정한 수준에서 통제될 필요가 있고, 노동법은 이를 목적으로 하는 법 영역이기 때문이다.

4) 이러한 점에서 근대적 기업에서의 생산의 경우에는 민법 제259조 제1항의 “타인의 동산에 가공한 때에는 그 물건의 소유권은 원재료의 소유자에게 속한다. 그러나 가공으로 인한 가액의 증가가 원재료의 가액보다 현저히 다액인 때에는 가공자의 소유로 한다.”라는 가공의 법리가 적용될 여지가 없다.

한편, 임금에 관한 현행법의 내용을 기준으로 범주화해보면, 크게 ① 임금 지급의 보호에 관한 규정(근로기준법상 임금 지급의 원칙, 압류의 제한 등), ② 임금수준의 보호에 관한 규정(직접적으로는 최저임금 제도, 간접적으로는 동일노동 동일임금의 원칙 등), ③ 각종 법정수당 등의 산정을 위한 기술적 규정(평균임금, 통상임금 등)으로 나누어 볼 수 있을 것이다. 필자는 임금 관련 법제의 핵심은 임금의 보호에 관한 부분, 즉 ①과 ②라고 생각한다. 그런데, 종래 우리나라에서 임금에 관한 논의는 임금의 보호 자체가 아니라, 평균임금과 통상임금이라는 도구적 개념의 해석 문제에 무게 중심이 기울어져 있었다고 생각된다. 그러나, 평균임금과 통상임금은 각종 법정수당 등의 산정을 위하여 기술적으로 정의된 ‘도구’ 개념일 뿐이므로, 이러한 도구개념들은 그 산정방법만 명확하다면(구체적으로는, 사용자가 자의적으로 그 값을 변경할 수 없다면) 그 내용을 어떻게 정의하든 중요한 문제는 아니라고 생각한다. 예컨대, 통상임금의 개념을 엄격하게 정의하여 그 액수가 낮은 수준으로 고정된다면, 필요한 경우 각종 수당에 적용할 할증률을 상향 조정하면 될 터이다(예컨대, 연장근로수당 산정 시 적용할 의 할증률을 통상임금의 1.7배로 정하는 등). 그런데, 이처럼 평균임금과 통상임금은 본질상 ‘도구개념’에 불과함에도, 종래 우리나라에서는 통상임금의 범위를 둘러싼 다툼이 끊이지 않았고, 이러한 해석상 다툼은 근로기준법이 제정된 지 70년이 넘게 지난 현재까지도 이어지고 있다. 이러한 상황은 종래의 ‘판례’ 법리가 무언인가 ‘매우’ 잘못되어 있다는 합리적 의심을 품게 한다.

이에 필자는 이 글을 통하여 조금 거시적인 관점에서 우리나라의 임금 법제의 현황을 조망하고, 향후 개선방안을 모색해 보고자 한다. 이를 위하여 임금의 개념, 평균임금 및 통상임금의 해석, 임금의 보호에 관한 기존의 해석론의 문제점을 살펴보고, 이들 문제점에 대하여 필자 나름의 개선방안을 제시해 보고자 한다.

II. 임금의 개념

1. 근로기준법상 ‘임금’의 정의의 연혁

현행 근로기준법 제2조 제1항 제5호는 ‘임금’을 “사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.”라고 정의하고 있다. 한편, 1953. 5. 10. 법률 제286호로 제정되어 같은 해 8. 9. 시행된 제정 근로기준법 제18조는 “본법에서 임금이라 함은 사용자가 근로의 대상으로 근로자에게 임금, 봉급 기타 여하한 명칭으로든지 지급하는 일체의 금품을 말한다.”라고 정의하고 있었다. 현행법상 임금의 정의는 1953년 제정 당시의 정의에서 ‘근로의 대상(對償)’이라는 문구가 ‘근로의 대가(對價)’라고 변경된 것 외에는 1953년 제정 근로기준법의 내용과 동일하다.

이러한 1953년 제정 근로기준법상 임금의 정의는 1947년 제정된 일본 노동기준법(労働基準法)⁵⁾ 제11조의 임금의 정의인 “이 법률에서 임금이란 임금, 급료, 수당, 상여, 그 밖에 명칭 여하를 불문하고 노동의 대상(對償)으로 사용자가 노동자에게 지급하는 모든 것을 말한다.”라는 조문을 그대로 들여온 것이다. 일본의 경우 1911년 제정되어 1916년 시행된 공장법(工場法)은 임금에 관하여 명시적인 정의조항을 두고 있지 않았다. 일본에서 실정법으로 임금이 정의된 것은 일본이 제2차 대전의 전시총동원 체제하의 노동력 부족에 따른 임금상승으로 인한 물가 상승을 억제하기 위해 국가총동원법(國家總動員法) 제6조에 근거하여 칙령(勅令)으로 제정한 1939년 임금통제령(賃金統制令)⁶⁾ 제3조 제1항에 그 연원을 두고 있다.⁷⁾ 위 조항은 처음에는 간결한 정의지만, 이듬해인 1940년 전면 개정⁸⁾을 통하여 “본령에서 임금이라 함은 임금, 급료, 수당, 상

5) 昭和22年法律第49号.

6) 昭和14年3月31日勅令128号.

7) 荒木尙志・岩村正彦・村中孝史・山川隆一 編, 注釋労働基準法・労働契約法 第1卷, 有斐閣, 2023, 196쪽. [이케다 히사시(池田悠) 집필부분]

8) 昭和15年10月19日勅令675号.

여금 기타 명칭을 불문하고 노동자를 고용한 자(이하 ‘고용주’라 칭함)가 노동에 대한 대상(對償)으로 지급하는 금전, 물건 기타의 이익을 말한다.”라고 개정되었고, 이러한 임금의 정의가 1947년 노동기준법 제정 시 임금의 정의로 도입된 것이다.⁹⁾

한편, 일본의 공장법이 식민지 조선에 적용되지 않았던 것과는 달리, 국가총동원법(國家總動員法)은 “국가총동원법을 조선·대만 및 화태(樺太)¹⁰⁾에 시행하는 건”을 통하여 1938년 제정 당시부터 조선에 의용(依用)되었으며, 동법에 근거한 칙령인 임금통제령(賃金統制令)도 조선에 실시되었다.¹¹⁾ 이러한 점에서 보면, 1953년 제정 근로기준법상 임금의 정의는 연혁적으로 제국주의 일본이 제2차 대전 전시체제에서 임금상승을 억제하기 위해 임금의 범위를 ‘폭넓게’ 정의했던 임금통제령(賃金統制令)에 출발점을 두고 있다고 평가할 수 있을 것이다.

2. 근로기준법상 ‘임금’ 개념의 정의와 기능

1) 정의

근로기준법 제2조 제1항 제5호의 법문(法文)에 근거하여 도출되는 임금의 요건은 ① 근로의 대가일 것과 ② 명칭을 불문하고 사용자가 지급하는 모든 금품일 것의 두 가지뿐이다. 따라서, 이러한 두 가지 요건을 충족하는 금품은 근로기준법상 임금에 해당한다.

한편, 임금에 관한 근로기준법상 제반 규정은 벌칙의 부과를 통하여 사용자에게 그 이행을 강제하고 있음은 물론, 근로 조건의 기준으로서 사법(私法)적 강제성(강행적 효력)을 갖는다(근로기준법 제15조). 따라서, 근로기준법상 임금의 범위는 당사자의 의사(意思)에 의해 결정되는 것이 아니라, 각 규정의 취지에 비추어 ‘객관적’으로 확정되어야 한다(사실 우선의 원칙). 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 법문 중 “명칭을 불

9) 荒木尙志 외 編, 앞의 책, 197쪽. [이케다 히사시(池田悠) 집필부분]

10) 사할린을 말한다.

11) 배성준, “일제말기 통제경제법과 기업통제”, 『한국문화』 제27호, 서울대학교 규장각한국학연구원, 2001, 371쪽.

문하고”라는 부분은 이러한 점을 확인하는 취지로 이해된다. 다만, 개별 기업의 상황에 따라 근로자에게 현실적으로 금품이 지급되는 모습이 매우 다양하다는 점을 고려할 때, 사용자가 근로자에게 지급한 어떠한 금품의 임금성을 판단하는 과정에서는 사용자가 그러한 금품을 지급하게 된 구체적인 사정이 고려되어야 할 것이다(fact-specific). 이러한 점에서, 종래 특정한 금품의 임금성을 판단한 다양한 판결례와 고용노동부의 행정해석은 근로기준법상 임금성의 해석에 관한 어떠한 ‘일반원칙’을 세운 것이라기보다는, 개별 사안에서 임금성이 문제 되는 특정한 금품의 임금성을 그러한 문제가 발생한 특정 규정 적용의 맥락에서 판단한 것이라고 제한적으로 이해해야 할 것이다. 이는 앞서 본 바와 같이, 근로기준법의 법문에서 규정하는 임금성의 요건은 ① 근로의 대가일 것과 ② 명칭을 불문하고 사용자가 지급하는 모든 금품일 것의 두 가지뿐이고, 나아가 이러한 임금의 정의는 근로자의 임금을 최대한 폭넓게 파악하려는 취지의 규정이기 때문이다.

2) 기능

근로기준법 제2조 제1항 제5호에서 정의하는 ‘임금’은 규범적 개념이다. 따라서, 경제학, 경영학 등 기타 학문 영역에서 사용되는 임금개념과는 구별할 필요가 있다.

이러한 규범적 개념으로서의 임금개념이 적용되는 실정법 조항은 매우 다양하다. 먼저, 이러한 임금개념은 근로기준법 제6조 균등한 처우, 동법 제17조 제1항 제1호 근로계약을 체결할 때 임금 명시, 동법 제21조 전차금이나 그 밖에 근로할 것을 조건으로 하는 전대(前貸) 채권과 임금의 상계 금지, 동법 제36조 금품 청산, 동법 제37조 금품 청산에 대한 지연이자율의 가중 적용, 동법 제38조 임금채권의 우선변제, 동법 제43조 임금 지급 원칙, 동법 제44조 도급 사업에 대한 임금 지급 보호, 동법 제44조의2 건설업에서의 임금 지급 연대책임, 동법 제44조의3 건설업의 공사도급에 있어서의 임금에 관한 특례, 동법 제45조 비상시 지급, 동법 제46조 휴업수당, 동법 제47조 도급제 근로자에 대한 일정액 임금 보장, 동법 제48조 임금대장 작성, 동법 제49조 임금의 시효, 동법 제56조 연

장근로·야간근로·휴일근로에 대한 임금 가산 지급, 동법 제93조 제2호 임금 사항의 취업규칙 기재, 동법 제94조 임금에 관한 취업규칙 불이의 변경 시 근로자 측 동의 필요, 동법 제95조 취업규칙 감급 규정의 제한 및 동법 제107조부터 제116조까지 규정된 위 조항 위반에 대한 형사벌 또는 과태료의 제재 등 다양한 조항을 적용하는 전제가 된다. 다음으로, 최저임금법 제6조의 최저임금액 이상의 임금 지급, 남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제8조의 동일가치 노동 동일임금 보장, 근로자퇴직급여 보장법 제8조의 계속근로기간 1년에 대해 30일분 이상 평균임금 퇴직금 지급 제도 설정 의무 및 동법 제12조의 퇴직급여 등 채권의 우선변제, 파견근로자보호 등에 관한 법률 제21조의 차별 처우의 금지 및 시정 등 및 동법 제34조 사용사업주의 임금 지급 연대책임, 임금채권보장법 제7조의 체불임금의 국가 대지급 등 다양한 노동관계법령에서도 근로기준법상 임금개념이 사용되고 있다.

임금과 관련한 근로기준법 기타 노동관계법령의 제반 규정은 기본적으로 ‘근로자의 보호’를 목적으로 하는 것이다. 따라서, 근로기준법 제2조 제1항 제5호가 “사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.”라고 하여 임금의 범위를 폭넓게 정의한 것은 이러한 근로자의 보호라는 목적을 고려한 것으로 이해할 필요가 있다.¹²⁾ 그러므로, 근로기준법 제2조 제1항 제5호가 규정하고 있는 임금의 의미와 범위는 이러한 입법 취지를 고려하여 가능한 한 넓게 해석되어야 하며, 형식적인 문언의 의미에 집착해서는 안 될 것이다.¹³⁾

한편, 근로기준법 제2조 제1항 제5호는 근로기준법상의 제반 규정을

12) 물론, 임금개념에 관한 이러한 정의의 연원이 되는 일본의 1940년 개정 임금통제령(賃金統制令)은 인플레이션 억제를 위해 임금의 인상을 제한하기 위한 취지에서 임금의 개념을 넓게 정의한 것이지만, 일본의 1947년 노동기준법이나 우리나라의 1953년 근로기준법이 임금통제령에서 폭넓게 정의했던 임금의 정의를 그대로 수용한 것은 근로자의 임금을 폭넓게 보호하기 위한 취지로 이해할 필요가 있다.

13) 同旨: 金子征史·西谷敏 編, 基本法コンメンタル 労働基準法[第四版], 日本評論社, 1999, 37쪽 이하. [모리 세이고(盛誠吾) 집필부분].

적용하는 전제가 되는 임금개념을 ‘일반적’으로 정의한 것이기는 하나, 이러한 ‘일반적’ 정의가 임금에 관한 다양한 조항에 반드시 확일적으로 적용되어야 한다고 보기는 어렵다. 오히려 임금에 관한 개별 규정의 취지나 목적을 고려하여 임금의 개념을 어느 정도 상대적으로 해석할 필요가 있다. 예컨대, 임금에 관한 개별 규정 중 임금의 보호를 위한 조항은 임금개념을 넓게 제시할수록 보호되는 대상이 확대되어 근로자에게 유리하게 작용하는 반면, ‘임금액’에 관한 규제인 근로기준법 제47조 도급제 근로자에 대한 일정액 임금 보장이나 최저임금법 제6조의 최저임금액 이상의 임금 지급의 경우에는 임금개념을 넓게 파악할수록 그러한 최저금액의 달성이 쉬워진다는 점에서 근로자에게 불리하게 작용할 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 해석 시에는 기본적으로 근로기준법상의 임금개념을 폭넓게 파악하되, 문제가 되는 개별 조항에 임금개념을 적용할 때에는 해당 개별 조항의 취지를 고려하여 합목적적으로 수정할 필요가 있다고 이해해야 할 것이다.¹⁴⁾

요컨대, 임금의 범위를 근로기준법 등의 개별 조항의 취지를 고려하여 합목적적으로 수정할 수 있다고 이해하여야만 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금의 정의 규정과 임금의 보호에 관한 근로기준법 등의 개별 조항의 관계를 모순 없이 파악할 수 있게 된다. 예컨대, 임금에 관하여 통화(通貨) 지급의 원칙¹⁵⁾이 규정되어 있는 것은 사용자가 임금을 지급할 때 이를 통화로 지급해야 한다는 규범적 요구를 규정한 것이지, 반대로 통화 이외의 현물(in-kind)로 지급된 금품은 임금이 아니라는 식의 해석하는 근거가 되어서는 아니 될 것이다. 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 임금의 정의는 임금의 보호에 관한 근로기준법 등의 개별 규정을 적용하기 위한 요건(要件)을 정한 것이다. 따라서, 어떠한 임금에 대하여 개별 규정에서 예정하고 있는 법률효과를 그대로 적용하는 경우 참을 수 없는 불합리가 예상된다면, 법원(法院)은 그러한 개별 조항을 최대한

14) 荒木尙志 외 編, 앞의 책, 198쪽. [이케다 히사시(池田悠) 집필부분]

15) 근로기준법 제43조(임금 지급) ① 임금은 통화(通貨)로 직접 근로자에게 그 전액을 지급하여야 한다. 다만, 법령 또는 단체협약에 특별한 규정이 있는 경우에는 임금의 일부를 공제하거나 통화 이외의 것으로 지급할 수 있다.

축소하는 방향으로 해석하여 구체적 타당성을 도모하고, 나아가 만약 문언의 범위를 넘은 법 발견이 필요할 경우라면 ‘목적론적 축소’의 방식에 의한 법형성(法形成)을 모색해야 할 것이지, 거꾸로 일부 조항의 적용상 문제를 들어 특정한 금품의 ‘임금성’ 자체를 부정하는 방식으로 문제해결을 도모하는 것은 잘못된 방법론이다.

3. 임금의 구체적인 판단 방법

1) ‘근로의 대가’일 것

임금은 ‘근로의 대가’로 지급되는 금품이다. 그런데, 쌍무계약인 근로계약에서 주된 채권·채무 관계를 구성하는 것은 사용자의 지휘·명령에 따른 근로자의 노무 제공 및 이러한 노무 제공과 교환하여 사용자가 지급하는 임금이다.¹⁶⁾ 근로기준법 제2조 제1항 제5호에서 임금성의 요건으로 ‘근로의 대가’를 명기한 취지는, 사용자가 근로자에게 지급한 금품이라도 근로계약 이외의 법률관계에 근거한 것이나, 근로관계에 기반한 것이더라도 사용자의 의무로서가 아니라 임의로 지급한 것은 임금의 범위에서 ‘특별히’ 배제하려는 것이라고 이해하여야 할 것이다.¹⁷⁾ 그렇다면, 사용자가 근로자에게 지급한 금품의 임금성을 ‘특별히’ 부정하기 위해서는 법률적으로는 그러한 금품의 지급에 관하여 근로계약과는 별도의 ‘독립적인 증여계약’ 등이 (적어도 묵시적으로) 체결된 것으로 구성할 수밖에 없을 것이다. 따라서, ‘근로의 대가’ 여부를 판단하는 데 있어 근로계약에 따라 사용자에게 지급의무가 있는 금품은 원칙적으로 ‘근로의 대가’로 사실상 추정(推定)되고, 그러한 금품의 임금성을 다투고자 하는 측에서 별도의 ‘독립적인 증여계약’의 성립 등의 사정을 들어 그러한 추정을 복멸시켜야 하는 것으로 보는 것이 합리적이라고 생각한다.

¹⁶⁾ 근로기준법 제2조 제1항 제4호: “‘근로계약’이란 근로자가 사용자에게 근로를 제공하고 사용자는 이에 대하여 임금을 지급하는 것을 목적으로 체결된 계약을 말한다.”

¹⁷⁾ 同旨: 金子征史·西谷敏 編, 앞의 책, 38쪽. [모리 세이고(盛誠吾) 집필부분].

2) 사용자가 지급하는 모든 금품일 것

사용자가 근로자에게 ‘지급하는’ 금품이란 사용자가 실제로 지급하는 것뿐 아니라 사용자가 근로자에게 ‘지급하여야 할’ 금품도 포함하는 것으로 해석된다. 설령 사용자가 현실적으로 근로자에게 지급하지 않더라도 법적으로 지급의무가 있는 것은 근로기준법상 임금으로서 그 지급방법이 강제되고, 평균임금 산정에 산입되는 것이 당연하기 때문이다. 한편, ‘지급’이라는 말도 금품의 현실적 수취(受取)로 제한되는 것은 아니라고 해석해야 할 것이다. 만일, ‘지급’을 금품의 현실적 수취로 좁게 해석한다면, 사용자가 근로자에게 직접 지급하지 않은 재산상 이익의 임금성은 부정될 수밖에 없다는 점에서 부당한 결과가 발생할 수 있다. 그러므로, 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 ‘모든’이라는 문언에 근거하여 ‘지급’의 의미를 금품의 현실적인 수취 외에도 채무변제행위 등을 포함한 일체의 ‘이익의 제공’을 포함하는 의미로 해석할 필요가 있다. 요컨대, 근로기준법 제2조 제1항 제5호에서 말하는 ‘지급’이란 사용자의 지시에 따라 어떠한 금품(경제적 이익을 포함)이 근로자의 지배 영역에 놓이는 것이라고 넓게 해석하는 것이 합리적이라고 생각한다. 이러한 해석에 의하면, 종래 임금성이 부정되던 고객이 지급한 봉사료(tip)도 일률적으로 그 임금성을 부정해서는 안 될 것이다. 물론, 이러한 봉사료의 임금성이 긍정된다고 해서, 그러한 봉사료에 임금에 관한 근로기준법의 제반조항이 확일적으로 적용될 수는 없을 것이다. 따라서, 앞에서 언급한 임금개념의 상대성에 근거하여 개별 조항의 취지에 따라 해당 조항이 임금성이 긍정되는 봉사료에 적용될 성질의 것인지 개별적으로 판단해야 할 것이다.

3) 정리

근로기준법 제2조 제1항 제5호는 “임금”을 “사용자가 근로의 대가로 근로자에게 임금, 봉급, 그 밖에 어떠한 명칭으로든지 지급하는 모든 금품을 말한다.”라고 정의하고 있다. 따라서, 사용자가 근로자에게 지급한 금품이 임금에 해당하려면, 그러한 금품이 ‘근로의 대가’로 지급되는 것

이어야 한다. 다만, 현실적으로 위 법문에서 ‘사용자가 …… 근로자에게 지급하는 모든 금품’이라는 부분이 문제 되는 사안은 많지 않으므로, 대다수 사안에서 임금성의 판단은 ‘근로의 대가성’이라는 하나의 기준으로 판단하면 충분할 것이다. 나아가, 이러한 판단은 ‘사실 우선의 원칙’에 입각하여 특정 금품의 명칭이 아니라, 그 실질에 따라 판단하여야 함은 물론이다. 따라서, 어떠한 금품이 그 지급 사유의 발생이나 지급액이 불확정적이고 가변적이라도, 그러한 금품이 ‘근로의 대가’로 지급된 것으로 긍정된다면 임금에 해당한다고 보아야 할 것이다.¹⁸⁾ 다만, 이러한 ‘근로의 대가성’ 여부를 따지기 전에 그러한 금품의 지급에 관한 사용자의 의무(義務)는 긍정되어야 할 것이다. 물론, 이러한 지급의무를 임금성의 요건으로 보지 않는 견해도 있지만,¹⁹⁾ 필자는 사용자가 ‘지급의무 없이’ 지급한 금품은 사실상의 증여일 뿐, 임금으로 볼 수는 없다고 생각한다.

한편, 어떠한 금품의 지급에 관한 사용자의 ‘의무’는 기본적으로 당사자의 의사 합치, 즉 ‘계약’이 있는 경우에만 성립한다.²⁰⁾ 물론, 그러한 합의는 단체협약과 같이 집단적 차원에서 이루어지기도 하고, 근로계약과 같이 개별적 차원에서 이루어지기도 한다. 하지만, 결국 그러한 금품 지급의무는 사용자의 의사에 기초하여 성립될 수밖에 없다. 다만, 이러한 지급의무와 관련하여, 다소 기교적이지만 ‘추상적 의무’와 ‘구체적 의무’라는 개념을 상정할 필요가 있다. 몇몇 판결례에서 소위 ‘경영성과급’ 등 변동급의 임금성을 판단하는 표지로 ‘지급의무의 확정(確定)’ 등의 표현을 쓰는 경우가 있다. 고정급의 임금채권은 (근로자가 계약에서 정한 소정 근로를 이행함을 전제로) 그 성립과 동시에 채권액이 확정된다. 그러나, 변동급의 경우에는 임금채권이 성립하는 시기와 그 금액이 확정되는 시기가 달라진다. 예컨대, “2024년 12월에 회사의 경영성과를 고려하여

18) 권오성, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점-대답판결: 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결 -”, 『노동법논총』 제41집, 한국비교노동법학회, 2017, 236쪽 이하.

19) 유성재, 『판례노동법』, 법문사, 2008, 108쪽.

20) 다만, 근로기준법 등 법령에 따라 지급되는 법정수당 등의 임금성을 긍정하는 경우, 이러한 임금의 지급에 관한 의무는 당사자의 의사가 아니라 법률에 근거하여 발생하는 법정채권에 해당할 것이다.

경영성과급을 지급한다.”라는 계약(또는 단체협약)을 체결한 경우를 생각해 보자. 2024년 4월 23일 현재 임금채권은 ‘추상적’으로만 존재한다. 따라서, 구체적인 금액의 임금 지급을 소구(訴求)할 수는 없다. 그러나, 2024년 12월에 사용자에게 의하여 경영성과급의 액수가 확정되면 ‘구체적’ 임금채권으로 되고, 근로자는 이를 소구(訴求)할 수 있게 된다. 2024년 1월부터 2024년 12월의 기간 도중에 그 경영성과급의 지급 여부와 금액이 가변적이라고 하여(일부 판결례의 표현을 빌리자면 ‘확정’되지 않았다고 하여) 그러한 금품의 ‘근로의 대가성’이 부정될 수는 없는 것이다.²¹⁾

한편, 몇몇 판결례에서 ‘정기적, 계속적으로 지급되는 금원’ 등을 임금성 판단의 표지로 제시하고 있다. 그러나, 사용자가 근로자에게 어떠한 금품을 근로자에게 정기적, 계속적으로 지급해 왔다는 사실은, ‘아마도’ 사용자에게 그러한 금품을 근로자에게 지급할 ‘의무’가 있었을 것이라는 ‘강한 추측’의 근거가 될 수 있을 뿐, 그 자체로 독자적인 임금성의 판단 기준이 될 수는 없다고 생각한다. 상식적으로, 법문에 규정되지 않은 독자적인 판단기준을 추가하면 할수록, 임금개념의 외연(外延)은 좁아질 수밖에 없다. 따라서, 법문이 규정하지 않은 판단기준을 임의로 추가하는 해석은 임금의 범위를 부당하게 좁히는 결과를 초래할 뿐이다.

III. 평균임금과 통상임금의 해석론

1. 평균임금의 해석에 관하여

근로기준법 제2조 제1항 제6호는 평균임금을 “이를 산정하여야 할 사유가 발생한 날 이전 3개월 동안에 그 근로자에게 지급된 임금의 총액을 그 기간의 총 일수로 나눈 금액”으로 정의하고 있고, 동 시행령 제2조 제2항은 “평균임금 임금의 총액을 계산할 때에는 임시로 지급된 임금 및

21) 이러한 주장의 상세한 논거는 拙稿, “경영성과급의 임금성”, 『노동법률』 2020년 3월호, (주)중앙경제, 2020, 64쪽 이하 참조.

수당과 통화 외의 것으로 지급된 임금을 포함하지 아니한다.”라고 규정하고 있다. 따라서, 평균임금은 위 법령에 따라 산정하면 충분할 것이다.

그런데, 근속기간이 장기인 근로자가 퇴직할 경우, 평균임금 액수의 변화에 따라 퇴직금의 총액에 큰 차이가 발생한다는 점, ‘3개월’이라는 산정 기간을 넘는 기간을 주기로 하여 지급되는 임금(예컨대, 소위 ‘정기상여금’의 경우)의 취급에 관한 문제 등 위 법문을 ‘그대로’ 적용하기 어려운 사례가 존재하고, 이러한 문제를 해결하기 위해 종래 법원은 다양한 판례법리를 고안해 왔다. 다만, 이러한 판례법리 중에는 개별 사건에서의 평균임금 산정의 구체적 타당성을 도모하기 위하여, 그 전제가 되는 ‘임금성’ 자체를 부정하는 것으로 평가되는 판결들이 있다. 예컨대, 생산성 격려금(productivity incentive, “PI”) 및 초과이익 분배금(profit sharing, “PS”)이라는 명목으로 지급된 ‘경영성과급’의 임금성 여부가 다투어진 수원지방법원 2021. 2. 4. 선고 2020나55510 판결에서 법원은 “이 사건 PI 및 PS의 지급실태, 전체 급여에서 차지하는 비중[이 사건 PI 및 PS는 앞서 본 것과 같이 전혀 지급되지 않는 경우부터 최소 지급액(상여지급 기준 대비 60%)에서 최다 지급액(1,200%)까지 그 액수가 상이하여 전체 급여에서 차지하는 비중도 일률적으로 평가하기 어렵다], 근로제공과의 직접적 혹은 밀접한 관련성의 결여, 이 사건 PS 및 PI를 포함하여 평균 임금을 산정하여야만 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 산정하는 평균임금 제도의 취지에 부합하는 것이라고 보기도 어려운 점 등을 고려하여 보면, 원고들이 주장하는 사정만으로는 피고 회사에 이 사건 PI 및 PS의 지급의무가 있다거나, 그것이 근로의 대가로 지급된 임금에 해당한다고 단정하기는 어렵다.”라고 판시하였다. 그런데, 위 판결의 당부를 떠나, 위 판결이 PS 및 PI의 임금성 자체를 부정한 논거로 ‘이 사건 PS 및 PI를 포함하여 평균임금을 산정하여야만 근로자의 통상의 생활임금을 사실대로 산정하는 평균임금 제도의 취지에 부합하는 것이라고 보기도 어려운 점’을 들고 있는 것은 논의의 순서가 역전되었다는 비판을 피하기 어려울 것이다.

위 판결의 사안에서의 PS 및 PI의 임금성은 피고 회사가 근로자들에게 그러한 PS 및 PI를 지급한 이유가 무엇인가, 즉, 원래 피고 회사의 주

주(株主)들에게 분배돼야 할 이익(profit)을 근로자들에게 분여(sharing)한 것인가, 아니면 근로자들의 ‘과거’의 근로에 대한 보상 또는 ‘장래’의 생산성(productivity)에 대한 유인(incentive)으로 지급한 것인가라는 질문에 대한 대답에서 찾아야 한다.²²⁾ 만일, 위 PS 및 PI를 평균임금 산정에 반영할 경우, 퇴직금의 산정에 참을 수 없는 불합리가 발생한다면, (어렵더라도) 그러한 경영성과급을 ‘평균임금’ 산정에서 제외하기 위한 논증을 통해 문제를 푸는 것이 올바른 방법론일 것이다. 예컨대, “평균임금 임금의 총액을 계산할 때에는 임시로 지급된 임금 및 수당 ... 을 포함하지 아니한다.”라는 근로기준법 시행령 제2조 제2항에 근거하여 위 PS 및 PI가 (임금성은 긍정되지만) 평균임금 산정에서 제외된다는 논증을 모색하는 편이 평균임금의 취지를 언급하며 위 PS 및 PI가 임금이 아니라고 판단하는 것보다는 덜 어색할 것이기 때문이다.²³⁾

2. 통상임금의 해석에 관하여

1953년 제정 근로기준법은 시간외근로에 대한 할증임금의 계산을 위한 기준으로 ‘통상임금’이라는 용어를 사용하면서도 통상임금의 정의에 관해서는 규정하지 않았으며, 1954년 제정 근로기준법시행령에서 시급(時給)·일급(日給)·주급(週給)·월급(月給)이 통상임금에 해당함을 전제로

²²⁾ 위의 글, 67쪽.

²³⁾ 한편, 대법원 2010. 4. 15. 선고 2009다99396 판결은 “근로기준법 및 근로기준법 시행령 등이 정한 원칙에 따라 평균임금을 산정하였다고 하더라도, 근로자의 퇴직을 즈음한 일정 기간 특수하고 우연한 사정으로 인하여 임금액 변동이 있었고, 그 때문에 위와 같이 산정된 평균임금이 근로자의 전체 근로기간, 임금액이 변동된 일정 기간의 장단, 임금액 변동의 정도 등을 비롯한 제반 사정을 종합적으로 평가해 볼 때 통상의 경우보다 현저하게 적거나 많게 산정된 것으로 인정되는 예외적인 경우라면, 이를 기초로 퇴직금을 산출하는 것은 근로자의 통상적인 생활임금을 기준으로 퇴직금을 산출하고자 하는 근로기준법의 정신에 비추어 허용될 수 없는 것이므로, 근로자의 통상적인 생활임금을 사실대로 반영할 수 있는 합리적이고 타당한 다른 방법으로 그 평균임금을 따로 산정하여야 한다.”라는 판례법리를 제시하였는바, 성과급의 임금성이 긍정되더라도 위 판례법리에 따라 평균임금 산정에서 이를 제외하는 해석도 가능할 것으로 생각된다.

그러한 금액을 해당 기간의 ‘소정근로시간수’로 나누어 시급(時給)으로 환산할 수 있다고 규정하고 있었다. 이후 1982년 개정 근로기준법시행령에서 “근로자에게 정기적·일률적으로 소정근로 또는 총근로에 대하여 지급하기로 정하여진 시간급금액·일급금액·주급금액·월급금액 또는 도급금액”이라는 통상임금에 관한 ‘일반적’ 정의 규정이 도입되었다. 이후 주지하는 바와 같이, 법문에 규정된 ‘정기성’, ‘일률성’의 해석을 둘러싼 논란이 여전히 계속되고 있다.

1982년 개정 근로기준법시행령이 도입한 ‘정기성’, ‘일률성’ 개념에 관한 올바른 해석을 위해서, 통상임금의 해석에 관한 법원의 ‘판례법리’를 잠시 잊고, 시급(時給)·일급(日給)·주급(週給)·월급(月給)이라는 1954년 제정 근로기준법 시행령에서 이미 제시했던 통상임금의 전형적 유형에 공통되는 개념표지가 무엇인가를 새로이 궁리해 보았으면 한다. 필자는 1982년 개정 시행령의 ‘정기적·일률적’이라는 문구는 갑자기 하늘에서 떨어진 것이 아니라, 시급(時給)·일급(日給)·주급(週給)·월급(月給)이라는 전형적인 통상임금의 형태를 일관하는 공통된 개념표지를 추론해 낸 것으로 생각한다. 복수의 구체적인 규범들에서 하나의 일반원칙을 추론해 내고, 그러한 일반원칙을 유사한 다른 사실에 적용하는 것은 널리 수용되는 법형성의 방법론 중 하나이기 때문이다(이른바 ‘포괄유추(Gesamtanalogie)’에 의한 법형성).

이러한 관점에서 보면, 시급(時給)·일급(日給)·주급(週給)·월급(月給)의 공통점은 ① 일정한 ‘기간’에 대하여, ② 일정한 ‘비율’로 정한 임금이라는 점일 것이다. 여기서 일정한 기간을 ‘정기적’이란 말로, 일정한 비율을 ‘일률적’이란 말로 성문화(codify)한 것이 1982년 개정 시행령이라고 생각된다. 따라서, 필자는 ‘일률성’은 정해진 비율, 즉 ‘정률(定率)’로 고쳐 읽어야 한다고 생각한다.²⁴⁾ 이러한 점에서, ‘일률성’을 ‘모든 근로자’ 또는 ‘일정한 조건을 충족한 근로자’ 등의 의미로 파악해 온 종래의 판례법리는 근로기준법 시행령상 통상임금 정의 규정의 입법 연혁(沿革)을 전혀 고려하지 않은, 맥락을 찾기 어려운 자의적 해석이라고 생각한다.

24) 이러한 주장의 상세한 논거는 拙稿, “‘일률성’이란 무엇인가?”, 『노동법률』 2020년 2월호, (주)중앙경제, 2020, 57쪽 이하 참조.

다음으로, ‘정기성’에 관해서는 ‘임금 정기일 지급의 원칙’과의 관계를 고려할 필요가 있다. 근로기준법은 ‘매월 1회 이상’ 정기일 지급의 원칙을 규정하고 있으며, 시행령에서 이러한 원칙에 대한 몇 가지 예외를 규정하고 있다. 따라서 사용자가 근로자에게 비정기적으로 또는 ‘1개월을 넘는 기간을 주기’로 하여 지급한 임금의 경우에는, 먼저 그러한 임금 지급의 방식이 정기일 지급의 원칙의 ‘예외’로 허용될 수 있는가를 판단하는 것이 마땅하지, 이러한 규범적 평가를 건너뛰고 ‘위법할 수도 있는’ 지급 방식을 소여(所與)로 받아들인 상태에서, 그러한 임금의 통상임금성을 평가하는 타당한 방법론이 될 수 없다.²⁵⁾

3. 정리

임금성, 평균임금 및 통상임금의 개념에 관한 이상의 논의를 정리하면 아래 표와 같다.

<표 1> 임금성 등의 판단기준

지급의무 없이 지급된 금품	임금성 부정(다만, 이러한 금품이 장기간 반복하여 지급되는 경우 구 속력 있는 노사 관행으로 평가되는 경우, 임금성이 긍정될 수 있음)		
지급의무가 있는 금품	근로의 대가성 부정	임금성 부정 이러한 금품은 약정금의 성격을 가지므로 민사소송을 통하여 소구할 수 있으나, 임금채불에 대한 형사처벌 등 임금채권에 특별히 인정되는 보호의 대상에서 제외됨	
	근로의 대가성 긍정	소정근로 외	임금성 긍정
		근로의 대가 및 총근로의 보상	근로기준법 시행령 제23조에 해당하는 경우에는 정기일 지급 원칙의 배제 가능
		소정근로의 대가	임금성 긍정 정기일지급 원칙의 대상이므로, 정기성과 일률성이 긍정되어 통상임금에 해당

25) 러한 해석에 관한 상세한 논거는 拙稿, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점”, 『노동법논총』, 제41권, 한국비교노동법학회, 2017 및 拙稿, “‘재직 조건’ 정기상여금의 통상임금성”, 『중앙법학』, 제20권 제2호, 중앙법학회, 2018 각 참조.

IV. 임금의 보호

1. 임금의 ‘지급’에 관한 보호²⁶⁾

임금은 사용자가 근로자에게 ‘지급의무’를 부담하는 금품 중 근로의 대가성이 긍정되는 금품이다. 따라서, 사용자는 근로자에게 임금을 지급할 사법(私法)상 의무를 부담하므로, 임금에 관한 별도의 보호 입법이 없더라도 근로자는 민사소송을 제기하는 방법으로 임금을 소구(訴求)하고, 이러한 소송을 통하여 집행력을 획득하면 사용자(더 정확하게는 사업주)의 책임재산에 강제집행을 할 수 있다.

그러나, 임금의 지급 문제를 이러한 금전채권에 관한 일반적인 구제수단에만 맡겨둘 경우, 근로자의 현실적인 취약성 때문에 임금 지급에 관한 사용자의 부당한 행위에 적절하게 대응할 수 없다. 이에 근로기준법은 임금 지급의 4원칙을 규정하고, 이에 위반한 경우 형벌(刑罰)을 예정하고 있다. 그러나, 우리나라는 2023년 임금체불액이 1조 7,845억 원에 이르고 있으며, 피해근로자도 27만 5천 4백여 명에 이르고 있어,²⁷⁾ 임금체불에 대한 대응은 여전히 시급한 정책 과제이다. 이러한 임금체불의 발생원인을 소박하게 상상해보면 사용자가 ① 임금을 제 때에 지급하기 싫거나, ② 임금을 지급할 돈이 없거나, ③ 법정수당 등을 제대로 산정하지 못하는 등의 이유를 생각할 수 있을 것이다. 따라서, 임금체불을 근절하기 위하여는 이러한 각각의 원인에 대응할 수 있는 포괄적이고 다층적인 법제도 개선을 모색할 필요가 있다.

1) 민사법 영역에서의 개선방안

임금 지급의 확보와 관련하여, 먼저 소멸시효 기간의 연장이 필요하다

26) 이 부분은 拙稿, “임금체불 근절을 위한 법제도 개선방안”, 『법학논총』 제 44권 제1호, 한국대학교 법학연구소, 2020, 537쪽 이하의 내용을 요약 및 보완한 것이다.

27) 2024. 1. 25. 자 한국경제 인터넷판, “1조7845억…지난해 임금체불 ‘역대 최대’”. Available at <https://www.hankyung.com/article/2024012516301> (최종방문: 2024. 6. 8.)

고 생각한다. 2007. 12. 21. 법률 제8730호로 개정된 형사소송법은 법정형(法定刑)이 장기 5년 미만의 징역 또는 벌금에 해당하는 범죄의 공소시효를 5년으로 개정하였다(형사소송법 제249조 제1항 제5호). 이에 따라 임금채불죄의 공소시효는 종래의 3년에서 5년으로 변경되었다. 이로 인하여 임금채권의 민사상 소멸시효(3년)와 임금채불죄에 대한 공소시효(5년)가 상이해졌고, 그 결과 2007년 개정 형사소송법의 시행 이후에는 민사상으로는 3년의 소멸시효가 완성되었으나(즉, 사용자의 임금 지급의무는 소멸하였으나), 공소시효는 완성되지 않아 형사벌의 대상이 되는 사례가 등장하게 되었다.²⁸⁾ 민사상 임금 지급의무가 소멸하였음에도 사용자를 형사적으로 처벌하는 것이 적절한지의 문제와 관련해서는 다양한 입장이 있을 수 있겠으나, 입법으로 임금채권에 대한 소멸시효를 5년으로 개정함을 통하여 소멸시효와 공소시효의 균형을 맞추는 것이 이 문제에 대한 근본적인 해결방안이 될 수 있으리라 생각한다.

다음으로는, 임금의 매월 1회 이상 정기지급 원칙의 규범력을 제고시킬 필요가 있다. 근로기준법 제43조 제2항은 “임금은 매월 1회 이상 일정한 날짜를 정하여 지급하여야 한다.”라고 규정한다. 따라서, 임금의 지급 시기는 위 근로기준법 제43조 제2항의 제한을 받는다. 한편, 이러한 ‘매월 1회 이상 정기지급의 원칙’은 일본의 1916년 공장법 시행령²⁹⁾ 제22조에서 그 연원을 찾아볼 수 있다. 이후 1947년 제정된 일본 노동기준법 제24조 제2항 본문은 위 공장법 시행령 규정을 이어받아 매월 1회 이상 정기지급의 원칙을 규정하되, 그 단서에서 ‘임시로 지급하는 임금, 상여, 그 밖에 이에 준하는 것으로서 후생노동성령으로 정하는 임금’은 예외로 허용하였다. 같은 해 일본 노동성은 위 노동기준법 제24조의 시행에 관하여 “상여란, 정기 또는 임시로, 원칙적으로 근로자의 근무성적에 따라서 지급되는 것이며, 그 지급액이 미리 확정되지 않은 것을 말한다. 정기적으로 지급되고, 그 지급액이 확정되어 있는 것은 명칭의 여하에도 불구하고 이를 상여로 보지 않는다.”라는 행정해석을 제시하였고,³⁰⁾ 이

28) 강지현, “임금채권의 소멸시효 관련 실무상 쟁점”, 『변호사』 제49집, 서울 지방변호사회, 2016, 14쪽.

29) 大正5年8月3日勅令第193号.

러한 해석은 현재까지 그대로 유지되고 있다. 우리나라의 경우, 1953년 제정 근로기준법 제36조 제2항은 “임금은 매월 1회 이상 일정한 기일을 정하여 지급하여야 한다. 단 임시로 지급하는 임금, 수당 기타 이에 준하는 것 또는 대통령령으로써 정하는 임금에 대하여는 예외로 한다.”라고 규정하고 있었다. 위 조항은 단서 부분에서 일본의 노동기준법이 명시하고 있는 ‘상여’라는 말이 기재되지 않았다는 정도의 차이가 있을 뿐, 위 일본 노동기준법 제24조 제2항과 동일하다.³¹⁾ 한편, 대법원 1981. 11. 24. 선고 81다카174 판결은 “상여금이 정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정되어 있다면 이는 근로기준법 제36조 제2항 단서 및 동법시행령 제18조에 규정된 임시 지급의 임금과 같이 볼 수 없고 정기일 지급 임금의 성질을 띤 것이라고 보아야 하므로, 상여금 지급 기간 만료 전에 퇴직한 근로자라도 특단의 사정이 없는 한 이미 근무한 기간에 해당하는 상여금은 근로의 대가로서 청구할 수 있다.”라고 판시하였다. 동 판결은 정기적으로 지급되고 그 지급액이 확정된 금품은 그 명칭과 관계없이 ‘정기일 지급 임금’에 해당한다는 점을 명확히 하여 근로기준법 제43조 제2항의 적용 기준을 제시한 것이다. 따라서, 우리나라의 관행화된 고정급의 정기상여금 지급 방식은 근로기준법 제42조 제2항에 위반하여 무효이고, 따라서 사용자는 근로기준법의 강행적 효력에 따라 정기상여금을 매월의 임금지급일에 분할 지급해야 한다.³²⁾

다음으로, 임금체계의 단순화 및 투명성의 제고가 필요하다. 근로자가 자신의 임금이 얼마인지, 나아가 통상임금이 얼마인지 알 수 없는 상황에서 임금체불의 발생은 필연에 가깝다. 따라서, 임금성 및 통상임금성 판단기준은 근로자와 사용자의 측에서 ‘직관적’으로 알 수 있을 정도로 단순하고 명료해야 한다. 이를 위해서는 임금성 및 통상임금성 개념은 법문에 명시된 내용만을 기준으로 단순하게 판단되어야 한다. (이 부분

30) 労働基準法の施行に関する件(1947(昭22).9.13, 發基17号).

31) 위 조항은 현행 근로기준법 제43조 제2항에 그대로 유지되고 있다.

32) 이러한 해석에 관한 상세한 논거는 拙稿, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점”, 『노동법논총』, 제41권, 한국비교노동법학회, 2017 및 拙稿, “‘재직 조건’ 정기상여금의 통상임금성”, 『중앙법학』, 제20권 제2호, 중앙법학회, 2018 각 참조.

에 대한 논의는 앞의 III.의 논의로 갈음한다.)

한편, 임금채불에 대한 진정·고소를 통하여 채불 사실이 공권적으로 확인되어 ‘채불임금등사업주확인서’가 발급된 경우에도 사용자의 재산을 강제집행하기 위해서는 근로자는 새로이 임금청구의 소를 제기하여야만 한다. 따라서, 소송보다 간단하고 신속한 방법으로 ‘채불임금등사업주확인서’가 발급된 임금채권에 집행력을 부여하는 제도의 신설을 고려할 필요가 있다. 예컨대, ‘채불임금등사업주확인서’를 발급받은 근로자가 법원에 ‘채불임금등사업주확인서’에 기재된 금액에 대한 ‘집행권원’의 부여의 결정(決定)을 신청할 수 있도록 하는 제도의 도입을 고려할 수 있을 것이다. 이러한 결정은 기판력(既判力)은 인정되지 않으므로 결정에 이의가 있는 사용자는 채무부존재확인 소를 통하여 결정의 효력을 다룰 수 있겠지만, 이러한 채무부존재 확인 소에서는 임금의 부존재에 대한 증명책임이 그러한 소송의 원고인 사용자에게 돌아갈 것이라는 점에서도 피해근로자의 보호에 도움이 될 것으로 생각한다.

2) 형사법 영역에서의 개선방안

현행 근로기준법위반범죄 양형기준(2016. 3. 28. 의결, 2016. 7. 1. 시행)은 임금채불죄(양형기준의 표현으로는 “임금 등 미지급 관련”)의 양형기준을 다음과 같이 정하고 있다.

<표 2> 임금 등 미지급 관련 범죄의 양형기준

유형	구분	감경	기본	가중
1	5,000만 원 미만	~ 6월	4월 ~ 8월	6월 ~ 1년
2	5,000만 원 이상, 1억 원 미만	~ 8월	6월 ~ 1년	8월 ~ 1년6월
3	1억 원 이상	6월 ~ 1년	8월 ~ 1년 6월	1년 2월 ~ 2년 6월

이러한 양형기준은 임금채불죄의 양형을 사기, 횡령·배임범죄 등의 재산범죄와 같은 평면에서 바라보았다는 점에서 수궁하기 어렵다. 임금채불죄의 보호법익은 단순한 ‘재산’이 아니라 ‘생존권적 성격의 근로권

과 높은 관련성을 가지는 재산적 법익'이다. 하나의 회사에서 1억 원을 횡령하는 행위와 100명의 근로자에게 각 100만 원의 임금을 체불한 행위를 그 불법이나 책임의 정도가 같다고 볼 수는 없다고 생각한다. 따라서, 이러한 사정을 반영하지 못하고 있는 현행 양형기준은 임금체불죄의 보호법익의 본질을 충분하게 고려하지 못하였다는 점에서 개선이 필요한바, 특히 임금체불죄의 양형에 있어서는 '피해근로자의 수'와 '미지급 기간' 등은 반드시 고려되어야 할 것이다.³³⁾

나아가, 논의의 범위를 조금 확장해 보면, 우리나라의 개별적 근로관계에 관한 벌칙 규정은 처벌의 대상이 광범위한 측면이 있고, 또한 법정형(法定刑)의 수준도 높은 편이다. 그러나, 이처럼 형사벌의 대상이 넓음에도 불구하고 2019년 기준으로 기소된 사건 수가 2만 건이 넘는 등 근로기준법의 준수율이 높지 않은 것은, 이러한 처벌 규정이 실제로는 위하력을 발휘하지 못하고 있음을 시사한다. 이러한 점을 고려할 때, 악의적, 상습적 위반자에 대한 처벌의 강화는 반드시 필요할 것이다. 이를 위하여 상습범에 대한 가중처벌 조항을 신설하거나, 조세범 처벌법 제20조의 예를 참고하여 근로기준법 내에 “(제〇〇조부터 제〇〇조까지의) 벌칙행위를 한 자에 대해서는 형법 제38조 제1항 제2호 중 벌금 경합에 관한 제한 가중규정을 적용하지 아니한다.”라는 형법 적용의 일부 배제 조항을 신설할 필요가 있다.³⁴⁾

다음으로, 근로기준법 제109조 제2항은 동법 제36조, 제43조, 제44조, 제44조의2, 제46조 또는 제56조를 위반한 자에 대하여는 피해자의 명시적인 의사와 다르게 공소를 제기할 수 없다고 규정한다. 이처럼 임금체불죄를 반의사불벌죄로 규정한 것은 2005. 3. 31. 개정 근로기준법에서 체불임금에 대한 지연이자를 강화하는 대신 형사책임에 대하여는 반의사불벌죄로 규정하여 책임을 다소 완화한 것이다. 그런데, 임금체불죄를 반의사불벌죄로 규정함으로써 임금체불 행위가 국가 법질서를 위반하는

33) 이에 관한 상세는 拙稿, “임금체불의 형사법적 쟁점”, 『노동법포럼』 제24호, 노동법이론실무학회, 2018, 27-29쪽 참조.

34) 이에 관한 상세는 拙稿, “일백 번 넘게 연장근로 규정을 위반한 사용자에게 벌금 100만 원은 과연 정의로운가? - 대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도15393 판결”, 『노동법학』 제89호, 한국노동법학회, 2024, 349쪽 참조.

범죄가 아니라 단순한 사인 간의 채무불이행에 불과하다는 인식이 더욱 만연해진 것으로 보이며, 이는 결국 근로기준법 전반에 대한 준수율을 낮추는 결과를 초래할 것으로 생각된다. 따라서, 임금채불을 반의사불벌죄로 규정한 근로기준법 제10조 제2항을 폐지하거나, 적어도 피해자가 처벌불원의 의사의 표시할 수 있는 시기를 공소 제기 이전으로 제한할 필요가 있다고 생각한다. 또한, 피해자의 처벌불원 의사 외에 사용자가 채불임금을 변제하거나, 충분한 담보를 제공한 경우에만 공소권을 소멸시키는 방안도 고려할 필요가 있다고 생각한다.

3) 행정법 영역에서의 개선방안

전술한 바와 같이 우리나라의 근로기준법은 임금채불을 범죄로 처벌하고 있다. 그러나, 근로기준법의 준수율 제고를 위하여 형사벌의 수준을 강화하는 것이 유일한 해법은 아닐 것이다. 형사벌 이외의 다양한(행정적) 제재수단을 확대하여 검찰의 기소 및 법원의 재판을 거치지 않고 고용노동부가 적시에 행정적 이행강제수단을 활용하여 근로기준법 위반의 위법상태를 교정하는 방식을 도입할 필요가 있다고 생각한다.

미국의 경우를 살펴보면, 연방 수준에서 개별적 근로관계와 관련하여 처벌을 규정하는 경우는 많지 않고, 나아가 실제 기소 및 처벌된 사례는 매우 드물다. 이로 인하여, 미국에서는 임금 지급에 대한 준수율이 낮아진다는 문제 제기가 있었다. 예컨대, Progressive States Network라는 민간단체는 2012년 ‘Where Theft is Legal: Mapping Wage Theft Laws in the 50 States’라는 보고서에서 미국 50개 주의 임금 보호에 관한 주(州)법을 분석하고, 근로자에 대한 법적 보호에 따라 주(州)의 등급을 평가한 후 극히 소수의 주(동 보고서에 의하면 뉴욕, 매사추세츠, 코네티컷, 일리노이, 노스캐롤라이나, 캘리포니아의 6개 주)에서만 입법을 통하여 임금 절도 문제에 대응하고 있으며, 대다수 주에서는 입법적 보호가 매우 부실하다고 지적하였다.³⁵⁾

35) Tim Judson & Cristina Francisco-McGuire, “Where Theft is Legal: Mapping Wage Theft Laws in the 50 States,” Progressive States Network, June 2012, Available at www.researchgate.net/publication/326678129_Where_Theft_is_Le

이러한 비판에 대응하여, 미국의 다수의 주(州)는 2000년 이후 주법으로 임금 절도와 관련한 제재를 강화하는 입법을 도입하고 있다. 다만, 이러한 보호 입법은 임금채불에 대한 제재의 수단으로 형사벌의 방식을 도입하기보다는 ① 소위 ‘부가배상금(liquidated damages)’을 규정하거나(예컨대, 미지급액의 2배, 3배, 4배), ② 우리 법의 과태료 또는 과징금과 유사한 민사벌(civil penalty) 제도를 강화하거나, ③ 명단공표, ④ 담보권 설정, ⑤ 보증금의 예치 등 다양한 ‘행정적’ 제재를 사용하고 있다. 예컨대, 미국은 다수의 주는 최저임금 청구나 미지급 임금청구에 대하여 ‘3배 부가배상금’ 조항을 두고 있다(애리조나, 아이다호, 메인, 매릴랜드, 매사추세츠, 미시간, 뉴멕시코, 오하이오, 로드아일랜드).³⁶⁾ 한편, 플로리다주와 같이 집행체제가 약한 주의 마이애미-데이드(Miami-Dade) 카운티에서 2010년에 ‘3배 부가배상금’ 조항을 도입하였다.³⁷⁾ 나아가, 2013년 컬럼비아 특별구는 미지급 임금청구에 대해 ‘4배 부가배상금’을 최초로 도입하였다.³⁸⁾ 한편, 연방 차원에서는 공정노동기준법(Fair Labor Standards Act of 1938, “FLSA”)에 위반하는 행위(제15조)에 대해서는 민사벌(civil penalty) 제도를 두고 있는바, 특히 최저임금과 시간외임금에 관해서는 (재범 또는 고의를 요건으로) 매 위반 시 1,100달러를 그 상한액으로 하여 노동부 장관이 금액을 결정하여 위반자에게 지급하도록 명령할 수 있다(제16조(e)). FLSA상 민사벌은 국고에 귀속하는 것이고, 사용자가 이를 지급하지 않으면 노동부 장관이 소송을 통하여 이를 추심할 수 있다. 이러한 점은 미국의 각주의 임금 절도 방지 입법들은 어떠한 획일적인 방법을 취하는 것이 아니라 각 주(州)의 사정에 따라 다양한 대응방안을 모색하고 있음을 보여준다.

gal_Mapping_Wage_Theft_Laws_in_the_50_States

³⁶⁾ ARIZ. REV. STAT. ANN. § 23-364(g); IDAHO CODE ANN. § 45-615; ME. REV. STAT. tit. 26, §§ 626-A, 670; MASS. GEN. LAWS ch. 151, § 1B, 20; MD. CODE ANN. LAB. & EMPL. § 3-507.1; MICH. COMP. LAWS § 408.488; N.M. STAT ANN. § 50-4- 26(c); OHIO CONST. art. II § 34a.; R.I. Gen. Laws § 28-14-19.2.

³⁷⁾ Miami Dade Wage Theft Ordinance, Miami-Dade Municipal Code 22-2(h).

³⁸⁾ D.C. CODE ANN. § 32-1303.

이상의 논의를 정리하면, 미국의 각주의 임금 절도 방지 입법들은 어떠한 확실적인 방법을 취하는 것이 아니라 각 주(州)의 사정에 따라 다양한 대응방안을 취하고 있다. 이러한 사실은 어떠한 유형의 입법이 임금 절도 대응에 효과적인지를 선형적으로 알기 어렵다는 점과 각 주(州)의 입법은 해당 주에서 기존에 시행되고 있던 제도를 기반으로 이를 개선하는 방식으로 이루어지는 경향이 있다는 점을 시사한다. 예컨대, 캘리포니아주, 메릴랜드주 및 워싱턴주는 이미 2배 또는 3배의 부가배상금 및 민사벌을 부과하는 비교적 강력한 규제 체제를 갖추고 있었음에도 위반율이 계속 높았고, 이에 이들 주(州)에서의 입법은 기존의 절차를 강화하는 방향(즉, 새로운 소액 청구절차 도입 등)으로 진행되었다.

사실 제도적으로만 보면, 우리나라의 임금체불에 대한 제재규정은 비교법적으로 상당히 강력한 수준이다. 그러나, 앞서 본 바와 같이 그러한 제재가 현실적인 위하력을 발휘하지 못하는 징후 또한 뚜렷하다. 따라서, 형사벌 외에 다양한 행정적 제재수단을 도입하여 임금체불에 더 신속하고, 탄력적으로 대응할 필요가 있다. 구체적으로는, 우리나라의 경우 질서위반행위규제법의 제정으로 공법상 의무의 위반 이외에 사법상 의무의 위반에 대하여 과태료를 부과하는 것에 대한 이론적 다툼이 입법적으로 해결되었으므로, 향후 근로관계에서 사용자의 위반 행위에 대하여 과태료를 부과하는 방식으로 일부 처벌 규정을 비범죄화하는 것도 고려할 필요가 있다. 이 경우, 미국에서 매년 물가인상률을 고려하여 민사벌의 상한을 조정하는 것처럼, 과태료의 위하력이 유지될 수 있도록 물가인상에 따라 과태료 금액을 조정하는 제도를 함께 도입해야 할 것이다.

또한, 근래에는 노동관계법령에서도 종래 공정거래법 등에 규정하던 과징금 제도를 도입하는 사례가 있다.³⁹⁾ 이러한 과징금은 법령위반으로 인한 사업자의 부당한 이익의 박탈을 그 이유로 한다는 점을 고려할 때, 근로기준법 위반 행위 중에서 반사회성이 큰 행위 유형(예컨대, 반복적인 임금체불)에 대하여는 사용자의 부당한 이익을 환수한다는 취지에서

39) 이에 관해서는 拙稿, “소위 ‘기업살인법’ 도입 논의의 노동법적 함의”, 『노동법포럼』, 제28호, 노동법이론실무학회, 2019, 155쪽 참조.

과징금 제도를 도입하는 방안도 고려할 필요가 있다고 생각한다.

2. 임금 ‘수준’에 관한 보호

1) 적절한 최저임금의 필요성

근로계약은 본질상 노동자의 ‘시간’을 거래하는 계약이다. 근로자 측에서 보면, 근로계약은 삶의 수요를 충족하는데 필요한 소득을 얻기 위하여 생애 시간의 일부에 대한 처분권을 기업에 양도하는 거래이다. 한편, 개별 근로자의 노동력의 가치에 대한 평가(시장가치)는 근로자의 능력은 물론 경기변동 등에 따른 노동수요에 따라 가변적이겠지만, 삶의 수요를 충족하는데 필요한 소득은 어느 정도 확실성이 있다. 누구든 하루 세 끼를 먹어야 하며, 몸을 누일 곳이 필요하고, 몸에 걸칠 옷이 필요하며, 인간은 사회적 동물이기에 동료 시민과 교류하는데 드는 비용이 필요하기 때문이다.

최저임금과 생활임금의 문제는 기본적으로 근로자에게 ‘삶의 수요를 충족하는데 필요한 소득’을 보장한다는 관점에서 접근할 필요가 있다. 사실 현대 복지국가 모델은 국민의 다수가 근로계약을 통하여 자신의 그때그때의 삶의 수요를 감당함은 물론, 근로자라는 신분(status)에 근거하여 각종 사회보험에 편입되어 자신의 소득 일부를 실업, 노령 등 사회적 위험의 준비를 위하여 출연(出捐)함을 전제로 한다. 이것이 2차 세계대전 이후 현대 복지국가 형성의 토대가 된 ‘사회계약’이었다고 생각한다. 따라서, 근로계약을 체결하고 기업에 노동을 제공하였음에도 그 대가로 삶의 기본적인 수요의 충족에 필요한 소득을 획득할 수 없는 일이 빈번하게 발생한다면 복지국가의 전제가 되는 사회계약이 파탄에 이르게 될 것이고, 결국 현대 복지국가 모델 자체가 유지되기 어려울 것이다. 이러한 측면에서 ‘최저임금’ 제도는 현대 복지국가를 유지하는 중요한 안전판이라고 생각한다. 최저임금 제도가 이러한 안전판의 기능을 제대로 수행할 수 있기 위해서 적절한(decent) 수준의 최저임금 결정이 요구됨은 물론이다.

2) 변동급과 도급제(piece rate) 임금의 문제

카를 마르크스(Karl Marx)는 자본 1권(Das Kapital, Volume I)에서 변동급의 일종인 도급제 임금을 ① 노동의 질에 대한 관리가 쉽고, ② 노동 강도에 대한 관리가 쉬우며, ③ (기업 입장에서) 노동의 질이나 강도에 신경을 쓸 필요가 줄어들니 감독을 할 필요가 줄어 하도급을 양산할 수 있고, ④ 임금이 생산량에 따라 지급되기 때문에 노동자들은 임금을 더 받기 위해 스스로 노동 강도를 높일 수밖에 없고, ⑤ 노동자들의 개인 차이가 부각되어 경쟁 구도를 심화한다고 하면서, 도급제 임금을 “자본주의적 생산양식에 가장 적합한 임금형태”라고 비꼬듯 평가했다. 이러한 평가는 대부분의 변동급에도 동일하게 적용될 수 있을 것이다. 이러한 이해에 근거하여 필자는 전체 임금액 구성의 상당한 부분을 ‘변동급’으로 구성하는 방식의 임금체계에 반대한다. 다만, 앞에서 본 바와 같이 ‘적정한’ 수준의 고정급(decent fixed pay)이 보장됨을 전제로 이러한 고정급에 변동급을 추가로 지급하는 방식의 임금체계 도입은 적극적으로 고려할 필요가 있다고 생각한다.

앞서 언급한 바와 같이, 어떠한 임금체계를 취하든, 기업은 자신이 구매한 노동을 효율적으로 활용하여 더 많은 산출물을 획득하기 위한 다양한 노력을 하게 될 것이다. 이러한 노력은 신기술의 도입 등 노동 이외의 생산요소를 추가로 투입하는 방향에서 이루어질 수도 있을 것이고, 교대제나 변형근로시간제 등 기업이 확보한 총 근로시간을 보다 유연하게 사용하거나, 노동에 대한 감독을 강화하여 노동의 밀도(密度)를 높이는 방식으로 이루어질 수도 있을 것이다. 어떠한 방식이 되었든 이러한 노력으로 잉여가치가 발생한다.

그런데, 임금, 즉 노동의 교환가치는 사전에 확정적으로 정해지지만, 노동의 사용가치는 노동의 결과로 평가되므로 임금의 지급주기가 지난 후에야 확정된다. 사전에 결정된 노동의 교환가치와 사후에 확정되는 노동의 사용가치의 차액, 즉 잉여가치를 자본이 모두 독점하게 되면, 부자와 빈자 사이 격차는 더욱 확대될 것이다. 자신이 제공한 ‘노동력’에 대한 정당한 가치를 받지 못하는 노동자는 삶의 수요를 충족하기 위하여 불가피하게 장시간 노동을 강요받게 될 것이고, 장시간 노동은 노동

자의 노동력 손실을 초래하게 될 것이다. 이는 자본주의 체제 존속에도 결코 긍정적인 영향을 미치지 않을 것으로 생각한다. 따라서 기업은 성과급(임금이므로 회계상 비용으로 인식될 것임)의 방식으로 지급하든, 잉여금의 이익처분에 의한 ‘상여(賞與)’의 방식으로 분배하든 근로자집단과의 민주적 합의를 통하여 노동자의 잉여 노동으로 창출된 잉여가치 일부를 근로자에게 지급 또는 배당할 필요가 있다.

3) 임금체계 개편의 문제⁴⁰⁾

근래 정부 주도로 종래의 연공형 임금체계를 ‘공정한’ 임금체계의로 개편해야 한다는 요구가 강해지고 있다. 그런데, 특정한 임금체계와 ‘공정(fairness)’을 연결하는 관점에 대해서는 다소 의아한 구석이 있다. 임금과 관련한 ‘공정’의 문제는 어떠한 임금체계가 더 공정한가의 관점이 아니라, 보다 거시적인 관점에서 ‘노동소득분배율(ratio of compensation of employees to NI)’을 어떻게 향상할 것인가라는 관점에서 접근하는 것이 ‘공정’ 문제의 본질에 더 가깝지 않을까 생각한다. 총노동(總勞動)에 분배되는 소득이 같다면, 개별 기업 단위나 산업 또는 업종 단위에서 임금체계를 어떻게 설계하든 일종의 제로섬(zero-sum) 게임이 될 수밖에 없다고 생각한다. 이러한 상황에서 어떠한 임금체계가 더 공정하다고 외쳐 봐야 각 범주의 이·불리에 따른 새로운 투쟁의 장이 열릴 뿐이다.

그리고, 마치 재화 시장의 일물일가(一物一價)의 원칙처럼 전체 노동시장에서 하나의 직무(職務, job)에 하나의 가격이 설정되어 어느 기업에 속하든 같은 직무를 수행하는 근로자가 같은 임금을 받을 수 있다는 전제에서라면, 직무급(職務給, job classification wage)은 공정성의 제고와 밀접한 관련이 있다고 말할 수 있을 것이다. 그러나, 전체 노동시장이라는 거시적 관점이 아니라 하나의 ‘단일 기업 차원’에서 해당 기업의 임금체계를 연공급(年功給)으로 하든, 직무급으로 하든 이는 ‘공정’의 문제라기보다는 해당 기업의 인사관리의 ‘효율성’의 문제와 더 친한 것 아닌

40) 이 부분은 拙稿, “최근의 ‘임금체계 개편’ 논의를 바라보며”, 『노동법률』 2022년 12월호, (주)중앙경제, 2022, 104쪽 이하를 요약 및 보완한 것임을 밝혀둔다.

가 생각된다.

거칠게 말하면, 기업 측의 관점에서 효율적인 임금체계는 숙련된 근로자의 이직을 막는 동시에 양질의 근로자를 채용할 수 있으면서, 동시에 재직 중인 근로자에게 ‘동기부여’를 할 수 있는 임금체계일 것이다. 기업이 이러한 목적을 달성할 수 있는 효율적인 임금체계가 무엇인가를 고민하는 것은 자연스러운 일이라고 생각한다. 그런데, 이러한 기업 경영자의 ‘효율성’에 대한 고민을 ‘공정’의 문제로 치환하여 특정한 임금체계가 더 공정하고, 다른 임금체계는 덜 공정하다고 말하는 것은 “하지만 어떤 동물들은 다른 동물들보다 더욱 평등하다(but some animals are more equal than others)”라는 말을 생각나게 한다. 요컨대, 개인적으로는 개별 기업 차원에서의 직무급은 해당 기업이 자신이 선택한 임금체계의 정당성을 설득하기 위한 서사(敍事, narrative)의 소재 정도의 의미가 있다고 생각한다.

또한, 개별 기업이 임금체계를 어떻게 설계할 것인가는 기본적으로는 개별 기업 스스로 선택해야 할 문제라고 생각한다. “바람보다도 더 빨리 눕는” 풀처럼, 정부나 연구자가 말하기에 앞서 기업의 경영자들은 경영 환경, 노동환경의 변화를 감각적으로 먼저 감지하고 나름의 대응책을 모색해 왔고, 또 모색할 것이다. 따라서, 정부가 선제적으로 특정한 임금체계가 효율적(나아가 공정하기까지 하다고)이라고 결정하고, 그러한 결정에 따라 개별 기업 차원의 임금체계 변경을 촉진하는 것은 적절하지 않다.

사건으로는, 개별 기업에서의 임금체계 결정·변경의 국면에서 국가가 관심을 가져야 할 가장 시급한 과제는 임금체계와 관련한 기업과 근로자 사이의 ‘정보 불균형’의 해소라고 생각한다. 사실 임금체계의 결정 권한은 기본적으로 기업에 있다. 기업에 편입되어 ‘근로자’의 신분을 획득한 근로자는 기업에서 결정한 임금체계에 자신을 맡기게 된다. 따라서 근로자로서는 기업과 근로계약을 체결하기 전에 향후 어떠한 기준(임금 체계)에 따라 자신의 임금수준의 결정될 것인가를 알 수 있어야 한다(right to know). 한편, 근로계약의 체결 과정에서 당사자의 합의로 결정된 임금체계는 계약의 내용으로 편입될 것이고, 이러한 결정된 임금체계를 사후에 변경하기 위해서는 법률이 요구하는 절차를 거쳐야 한다. 계

약으로 결정된 임금체계의 변경에는 계약의 변경이, 취업규칙의 경우에는 취업규칙의 변경이, 단체협약의 경우에는 단체협약의 변경이 필요하다. 물론, 임금체계는 기업 단위에서 결정되는 것이므로 대부분 취업규칙이나 단체협약의 변경이 요구될 것이다.

일하는 방식의 변화나 산업전환 등 외부의 환경변화에 따른 임금체계의 변화는 노동체계 내부에서 체계 보존에 필요한 부분요소들을 끊임없이 재생산한다는 오토포이에시스(*autopoiesis*) 과정으로 평가할 수 있을 것이다. 국가가 해야 할 일은 ‘특정한 임금체계’가 더 공정하다고 말하는 것이 아니라, 노동체계의 오토포이에시스, 즉 자기 재생산 과정이 원활하게 구동될 수 있도록 조력하는 일이라고 생각한다. 예컨대, ① 개별 기업이나 근로자들이 알기 어려운 환경변화에 대한 객관적인 정보를 노사 당사자에게 공급하고, ② 외부환경의 변화에 응하여 임금체계의 변화를 모색하는 기업이 근로자들과 바람직한 임금체계의 변화 방안에 대하여 합리적으로 대화할 수 있는 메커니즘을 설계하고, ③ 혹여 임금체계를 변경하는데 요구되는 법적 절차가 너무나 경직되어 합리적으로 요구되는 임금체계의 변경이 불가능한 지경에 이르렀다면 관련 법률의 타당성을 재검토하여 국회의 논의를 통하여 법 제도의 개선을 모색하는 일이어야 한다고 생각한다.

나아가, 특정한 임금체계가 ‘공정하다’는 평가가 아니라 디지털화나 기후위기, 보건위기 등 노동체계 외부로부터의 충격에 대응하여 임금체계를 변경하는 과정에서 기업이 고려해야만 하는 사항이 무엇인지 명확하게 선언하는 것이 국가가 할 일이라고 생각한다. 거창하게 ‘정의로운 전환(*just transition*)’을 운운하지 않더라도, 이러한 대전환의 과정에서 특정 범주의 근로자들에게 경제적·사회적 희생이나 피해가 발생하지 않도록 하고, 또한 임금체계 변경과정에서 근로자의 집단적 목소리를 충분히 경청하고, 반영할 필요가 있다는 최소한의 원칙 정도는 명확하게 제시할 필요가 있다고 생각한다.

V. 맺으며

이상 본문에서는 임금의 개념, 평균임금과 통상임금의 해석, 임금의 보호 법제에 관한 기존 해석론의 문제점을 살펴보고, 해석론의 개선방안과 약간의 입법론을 개진하였다. 이 글의 논지를 요약하면 다음과 같다.

첫째, 근로기준법상 임금성의 판단은 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 법문에 기초하여 사실 우선의 원칙에 따라 ‘객관적’으로 이루어져야 하며, ‘근로의 대가성’의 판단 시에는 사용자에게 지급의무가 있는 금품은 원칙적으로 ‘근로의 대가’로 사실상 추정(推定)되고, 그러한 금품의 임금성을 다투고자 하는 측에서 별도의 ‘독립적인 증여계약’의 성립 등의 사정을 들어 그러한 추정을 복멸시켜야 하는 것으로 이해할 필요가 있다. 한편, 근로기준법 제2조 제1항 제5호에서 말하는 ‘지급’이란 사용자의 지시에 따라 어떠한 금품(경제적 이익을 포함)이 근로자의 지배 영역하에 놓이는 것으로 넓게 해석할 필요가 있다.

둘째, 평균임금의 산정과 관련하여 이례적으로 높은 성과급 등이 평균임금 산정에 반영 시 퇴직금의 산정에 참을 수 없는 불합리가 발생할 경우, 그러한 성과급의 임금성 자체를 부정하는 것이 아니라 그러한 성과급을 평균임금 산정에서 제외하기 위한 독자적인 논증을 통하여 불합리의 해결을 모색해야 한다.

셋째, 통상임금과 관련하여, 정기성·일률성의 개념은 시급(時給)·일급(日給)·주급(週給)·월급(月給)이라는 통상임금의 전형적인 형태를 일관하는 공통된 개념표지를 추론해 낸 것으로 이해할 필요가 있으며, 따라서 ‘일률성’은 정해진 비율, 즉 ‘정률(定率)’로 해석하는 것이 옳다.

넷째, 임금체불을 근절하기 위하여는 임금체불의 원인이 되는 다양한 사정에 대응할 수 있는 포괄적이고 다층적인 대응방안을 모색할 필요가 있으며, 특히 형사벌 외에 과태료, 이행강제금(부가배상금), 과징금 등 다양한 행정적 이행강제수단의 도입을 통하여 행정적 개입의 신속성을 향상할 필요가 있다.

다섯째, 임금체제와 관련하여 고정급 이외에 근로자집단과의 민주적 합의를 통하여 기업의 성과를 근로자에게 적정하게 분여(分與)할 수 있

는 제도적 토대를 설계할 필요가 있다. 다른 한편, 기업이 임금체계를 변경하는데 요구되는 법적 절차가 너무나 경직되어 합리적으로 요구되는 임금체계의 변경이 불가능한 상황에 이르지 않도록 관련 제도의 타당성을 검토하고, 국회의 논의를 통해 입법적 개선을 모색할 필요가 있다.

주제어: 임금, 평균임금, 통상임금, 임금체불, 최저임금

참고문헌

- 강지현, “임금채권의 소멸시효 관련 실무상 쟁점”, 『변호사』 제49집, 서울지방변호사회, 2016.
- 권오성, “경영성과급의 임금성”, 『노동법률』 2020년 3월호, (주)중앙경제, 2020.
- _____, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점-대상판결: 대법원 2017. 9. 26. 선고 2017다232020 판결 -”, 『노동법논총』 제41집, 한국비교노동법학회, 2017.
- _____, “소위 ‘기업살인법’ 도입 논의의 노동법적 함의”, 『노동법포럼』, 제28호, 노동법이론실무학회, 2019.
- _____, “‘일률성’이란 무엇인가?”, 『노동법률』 2020년 2월호, (주)중앙경제, 2020.
- _____, “일백 번 넘게 연장근로 규정을 위반한 사용자에게 벌금 100만 원은 과연 정당한가? - 대법원 2023. 12. 7. 선고 2020도15393 판결”, 『노동법학』 제89호, 한국노동법학회, 2024.
- _____, “임금체불 근절을 위한 법제도 개선방안”, 『법학논총』 제44권 제1호, 단국대학교 법학연구소, 2020.
- _____, “임금체불의 형사법적 쟁점”, 『노동법포럼』 제24호, 노동법이론실무학회, 2018.
- _____, “정기상여금에 붙은 ‘지급일 재직 조건’의 문제점”, 『노동법논총』, 제41권, 한국비교노동법학회, 2017.
- _____, “‘재직 조건’ 정기상여금의 통상임금성”, 『중앙법학』 제20권 제2호, 중앙법학회, 2018.
- _____, “최근의 ‘임금체계 개편’ 논의를 바라보며”, 『노동법률』 2022년 12월호, (주)중앙경제, 2022.
- 김형배·박지순, 『노동법강의』(제13판), 신조사, 2024.
- 배성준, “일제말기 통제경제법과 기업통제”, 『한국문화』 제27호, 서울대학교 규장각한국학연구원, 2001.
- 유성재, 『판례노동법』, 법문사, 2008.
- 이철수, 『노동법』, 현암사, 2023.
- 임종률·김홍영, 『노동법』(제21판), 박영사, 2024.
- 荒木尚志·岩村正彦·村中孝史·山川隆一 編, 注釋勞動基準法・勞動契約法 第1卷, 有斐閣, 2023.

金子征史・西谷敏 編, 基本法コンメンタール 労働基準法[第四版], 日本評論社,
1999.

Tim Judson & Cristina Francisco-McGuire, “Where Theft is Legal: Mapping
Wage Theft Laws in the 50 States,” Progressive States Network, June
2012.

<Abstract>

Revisiting Wage Legislation

KWON, Ohseong^{*}

This article aims to examine the current status of Korea's wage legislation from a macro perspective and explore potential avenues for its future improvement. It will delve into the concept of wages, the interpretation of average wage and regular rate of payment, and issues related to wage protection. It will identify problems with existing interpretations in each of these areas and propose strategies for future enhancement.

First, the determination of wage under the Labor Standards Act must be made 'objectively' in accordance with the primacy of fact doctrine, based on the legal text of Article 2(1)(5) of the Labor Standards Act. In determining the 'consideration for labor,' it is essential to recognize that, in principle, monetary items that the employer is obligated to pay are presumed to be 'consideration for labor.' The burden of proof falls on the party disputing the wageability of such items, who must demonstrate circumstances, such as the establishment of a separate gift contract, to counter this presumption. Meanwhile, 'payment' in Article 2(1)(5) of the Labor Standards Act should be interpreted broadly to encompass economic benefits under the control of the employee, including those under the direction of the employer.

Second, in relation to the calculation of the average wage, if an intolerable unreasonableness arises in the calculation of severance pay when unusually high performance pay is included in the average wage

^{*} Yonsei Law School, Associate Professor

calculation, it is necessary to address this unreasonableness by arguing for the exclusion of such performance pay from the average wage calculation, rather than by denying the wageability of the performance pay itself.

Third, in relation to regular rate of payment, the concepts of ‘uniformity’ should be understood as implying a common conceptual framework consistent with the typical forms of regular rate of payment, namely hourly wage, daily wage, weekly wage, and monthly wage. Consequently, ‘uniformity’ should be interpreted as a fixed or set rate.

Fourth, to eradicate wage arrears, it is necessary to develop a comprehensive and multi-layered response that addresses the various circumstances leading to wage arrears. Specifically, improving the speed of administrative intervention is crucial. This can be achieved by introducing various administrative enforcement measures such as fines, performance compulsion (additional compensation), and administrative penalties, in addition to criminal penalties.

Fifth, concerning the wage system, it is necessary to design an institutional framework that allows for the appropriate sharing of corporate performance with workers through democratic consensus with the worker group, in addition to fixed wages. Conversely, it is essential to review the adequacy of the relevant system and seek legislative improvements through parliamentary debate to ensure that the legal procedures required for companies to change their wage system are not excessively rigid, thereby enabling reasonable and necessary modifications to the wage system.

Key Words: Wage, Average Wage, Regular Rate of payment, Wage Arrears, Wage System